

1502080-66.2021.8.26.0537

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Patrícia Helena Hehl Forjaz de Toledo

Comarca: Diadema

Foro: Foro de Diadema

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 24/02/2022

... correram. O réu primeiramente confessou o tráfico, mas depois negou. Nas duas pochetes tinha drogas (crack, cocaína e maconha) e dinheiro. O local é um ponto de tráfico já conhecido. O horário era de noite. Reconhece o réu e não o tinha visto antes no local, um escadão com casas de moradia coletivas, mas onde o réu e o outro rapaz estavam, só tinha eles dois, e depois que ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Diadema

Foro de Diadema

2ª Vara Criminal

Avenida Sete de Setembro, 399, Diadema-SP - cep 09912-010

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502080-66.2021.8.26.0537 - Controle nº 2021/001556

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2289710/2021 - 03º D.P.

DIADEMA, 2289710 - 03º D.P. DIADEMA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Wilson Joaquim Ferreira Junior

Réu Preso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Patrícia Helena Hehl Forjaz de Toledo

Vistos.

WILSON JOAQUIM FERREIRA JUNIOR, qualificado às fls. 04/06, está sendo processado pela prática do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, porque no dia 22 de outubro de 2021, por volta das 20h50, na Rua Cardeal, altura do nº 130, bairro do Campanário, nesta cidade de Diadema, trazia com ele e guardava, para fins de entrega a consumo de terceiros, 139 embalagens e microtubos plásticos contendo 65,2g da droga cocaína, 57 embalagens plásticas contendo 29,7g da mesma droga, na forma de crack, e 71 embalagens plásticas contendo 46,81g da droga maconha, conforme auto de apreensão e exibição de fls. 14 e laudo de constatação provisória de fls. 23/26, agindo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Convertida a prisão em flagrante em preventiva (fls.44/47), a d. Advogada apresentou defesa inicial às fls.216/222. Não sendo hipótese de arquivamento, a

denúncia foi recebida em 26/11/2021 (fls. 233/234) e certificada a notificação e citação positiva do Réu a fls. 292.

Em audiência de instrução, debates e julgamento foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas Partes e interrogado o réu ao final. Encerrada a instrução sem requerimento de diligências, seguiu-se com os debates orais (tudo em mídia digital).

Nestes, o Órgão Ministerial requereu a procedência da ação por provadas autorias e materialidade delitivas. Pleiteou a fixação da pena base acima do mínimo diante da quantidade e nocividade da droga cocaína, discordando da redução da pena, e também de sua substituição pela pena restritiva de direitos, fixando-se regime prisional fechado, sem direito de apelo em liberdade, além da perda do dinheiro apreendido.

Já a d. Advogada reiterou o pedido de absolvição ante a fragilidade probatória. Subsidiariamente, requereu a desclassificação para porte de droga para uso próprio, e que a pena-base fosse fixada no mínimo legal, com o redutor da pena e sua substituição com fulcro no art. 44 do CP, fixando-se regime mais brando e possibilidade de recurso em liberdade, detração.

É o breve relatório.

Passo a fundamentar e decidir.

A ação procede.

A materialidade delitiva vem estampada no auto de exibição e apreensão de fls.28/29, nos laudos de constatação e no definitivo (fls.23/26 e 181/183), ambos positivos para as drogas maconha e cocaína.

A autoria é inconteste não só com fulcro na prova amealhada extrajudicialmente, como na colhida sob o manto do contraditório que corrobora àquela e a qual passo a expor.

Segundo narrativas administrativas dos policiais militares (fls. 02/03) efetuavam patrulhamento de rotina quando ao passarem pelo local já conhecido como ponto de venda de drogas, visualizaram dois indivíduos que correram ao visualizarem a viatura. Conseguiram capturar um deles, chamado Wilson, o qual estava na posse de duas pochetes/estojos pequenos, dentro dos quais havia diferentes tipos de drogas (cocaína, crack, maconha), individualmente embaladas, e R\$ 1.243,55 em dinheiro. Num primeiro momento, Wilson confessou informalmente aos policiais que estava traficando, porém, posteriormente, passou a negar que estava com a droga.

Neste sentido foi o depoimento judicial do policial Ricardo Oliveira, estavam em patrulhamento pelo local já tido como ponto de venda de drogas, e dois indivíduos avistaram a viatura e correram pela viela escura. O réu vinha com duas pochetes na mão contendo as drogas (crack, maconha, cocaína) e dinheiro (mil e duzentos reais). Reconhece o réu, quem inicialmente confessou o tráfico, mas depois negou no DP. Após a detenção, chegou um parente do réu que foi cientificado da prisão e compareceu no DP, mas não presenciou a prisão.

Sob o crivo do contraditório o policial Thalel Santana reiterou que estavam em patrulhamento e avistaram dois indivíduos que os viram e correram. Detiveram o réu com duas pochetes e nelas tinha drogas. O local é próximo de escola, UBS, e tinha moradores e crianças na rua, mas só eles dois correram. O réu primeiramente confessou o tráfico, mas depois negou. Nas duas pochetes tinha drogas (crack, cocaína e maconha) e dinheiro. O local é um ponto de tráfico já conhecido. O horário era de noite. Reconhece o réu e não o tinha visto antes no local, um escadão com casas de moradia coletivas, mas onde o réu e o outro rapaz estavam, só tinha eles dois, e depois que correram foi para local que tinha mais gente.

Correram atrás deles dois, mas um foi para o local sem saída, que era o réu, e por isso foi detido, e o outro suspeito correu para um local com saída, e por isso não foi alcançado nem detido. Não viu o réu lesionado na cabeça e por isso não o encaminharam ao hospital. As duas pochetes estavam na mão do réu e nas duas tinham drogas e dinheiro. Apreendidas, foram entregues ao delegado de polícia. As pessoas que presenciavam a prisão não querem depor e acabam sumindo para não serem arroladas como testemunhas.

A testemunha de defesa André, irmão do réu, ouvido como informante, disse que ele trabalha consigo e tinha saído do trabalho e ido para casa há pouco tempo. Sabe que o réu usa maconha. O tio do réu chegou no local após a prisão e os policiais lhe disseram que ele era culpado. Disseram que a abordagem foi bruta e depois o viu machucado. No local tem ponto de drogas, baile funk. Soube que o réu foi até lá para comprar uma droga para ele.

A testemunha de defesa Cícero não presenciou os fatos. Ele é seu conhecido porque convive com a mãe dele desde cedo. E que ele até os dezesseis anos dele frequentava a Igreja, mas depois foi conhecer o mundo, sair para baladas com supostos amigos, e tinha dúvida se ele também não passou a usar drogas. O réu trabalhava com o irmão fazendo banho e tosa de cachorro.

O réu, em solo policial (fl.04) negou a traficância e a posse das drogas. Afirmou que é usuário de maconha e que estava no local apenas para comprar uma porção de droga do traficante conhecido como "Zoio". A polícia militar chegou ao local e todos correram, inclusive ele, sendo pego em seguida pelos policiais. Aduziu que faz bicos na clínica veterinária em que seu irmão trabalha. Por fim, disse que não tem filhos; estuda (1ª série do ensino médio; supletivo); e não tem antecedentes criminais.

Em juízo o acusado alegou que não estava com as pochetes. Foi trabalhar e voltou as 17 horas. Descansou. Deu vontade de usar droga e foi comprar na biqueira. Tinha mais gente para comprar. O traficante gritou polícia. Todos correram. Foi alcançado e levou coronhadas e ameaças de morte dos policiais. Um policial entrou na viela e voltou com uma pochete com drogas, e ele teve que assumir. Reclamou no exame de corpo de delito que foi agredido pelos policiais. Não era usuário há muito tempo então não conhece o vendedor. Não chegou a comprar a droga. Mora ali perto. Na hora do ocorrido tinham moradores que até viram as agressões e pediram para os policiais pararem, e falou isso para sua Advogada, e não pensou em chama-los para depor como sua testemunha. Não foi processado antes e não conhecia os policiais antes. Trazia consigo apenas sua carteira com cinco reais para comprar uma maconha, e a chave de casa. Foi agredido com duas coronhadas e sob ameaça de morte de um dos policiais, assim que o outro desceu com a pochete, jogou nele mandando assumir, e o levaram preso.

Diante do exposto entendo haver prova cabal a embasar a condenação, com fulcro nos relatos uníssonos e harmônicos trazidos pelos policiais desde solo judicial, reiterado em juízo, ambos no sentido de que era o réu e um outro rapaz que estavam na biqueira, e assim que os viram, correram, mas só conseguiram dete-lo. O mesmo trazia em mãos duas pochetes e nas duas tinham drogas e dinheiro. Primeiramente ele confessou informalmente o tráfico, mas depois passou a negar. E em que pese o réu ter negado os fatos em solo policial, não indicou desde então estar ferido e que teriam sido um policial que lhe deu coronhadas, o que é no mínimo estranho, e também o fato dele já não ter dito desde então que moradores, seus vizinhos, viram sua prisão, e um deles até pediu para os policiais pararem de lhe agredir, mas estranhamente nenhum vizinho que presenciou a prisão foi arrolada pela Defesa a confirmarem o álibi do réu, dado que suas testemunhas não presenciaram os fatos, sendo de meros antecedentes criminais. Pois o que se verificou até pelo relato do réu, ele não tinha acabado de sair do trabalho, pois ele mesmo disse que foi para casa e descansou, e só depois saiu para comprar droga para seu uso. E outra contradição trazida por ele foi de que ia comprar droga com o Zoio, e em juízo

alegou desconhecer o traficante.

No mais, não é crível que os policiais, até então desconhecidos do réu, quem não tinha nada contra eles, tenham o incriminado injustamente, valendo-se de tantas drogas e uma quantia alta de dinheiro, dado que muito menos que isso o levaria preso. Tanto que apreendidas duas pochetes, o que demonstra que provavelmente seria do outro indivíduo que estava com o réu e que conseguiu fugir.

Não se alegue que o réu tenha sido agredido fisicamente pelos policiais para confessar o crime, pois em seu interrogatório policial (fl.04), ele negou os fatos. E como dito, estranhamente ele não trouxe testemunha presencial a confirmar tal agressão, nem a relatou à autoridade policial no momento oportuno. Assim, entendendo não poder se considerar tese defensiva de que a confissão informal, se houve, foi por ameaça.

Logo, os depoimentos dos testemunhos - que são válidos e eficazes para a condenação condenatória, até por não haver dúvidas sobre sua lisura - estão em consonância com os demais elementos probatórios contidos nos autos, sendo corroborados pelo auto de apreensão e exibição, além das provas periciais, sem prova contrária, já que sua negativa de autoria não veio devidamente demonstrada, já que as testemunhas de defesa não presenciaram os fatos, e Cícero, ainda, deixou claro que o acusado, desde os dezesseis anos, deixou de frequentar a Igreja, e se perdeu, caiu no mundo, fazendo coisas que pessoas que frequentam a Igreja não fazem, coisas ilícitas, prova esta que também não lhe favorece.

É cediço que no crime de tráfico de drogas, em regra, a prova é baseada nos depoimentos dos policiais. A defesa não apresentou nenhuma prova concreta capaz de ilidir as declarações dos policiais militares, não havendo motivo plausível para seu desmerecimento, consoante Enunciado 70 da Súmula de Jurisprudência do STJ.

Ora: o valor do depoimento testemunhal de servidores policiais especialmente quando prestado em Juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que suas declarações não encontram, suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos (STF, HC 76.608-0).

Ainda que não presenciado qualquer ato de comércio, as circunstâncias do flagrante demonstram a conduta prevista no art. 33, caput, da Lei de Drogas, que consigna como verbos nucleares trazer consigo e guardar, condutas perpetradas pelo réu, comprovada a circulabilidade. O tráfico de drogas é crime de ação múltipla e a prática de um dos verbos contidos no art. 33, caput, é suficiente para a consumação da infração, sendo prescindível a realização de atos de venda do entorpecente.

No mais, não procede a tese de se tratar de mero usuário, posto que não demonstrado cabalmente como lhe competia o ônus dessa prova. Ademais, a condição de usuário de drogas não afasta a traficância, uma vez que é comumente sabido que dependentes químicos utilizam o tráfico de entorpecentes como meio de perpetuar o vício, de modo que as condutas coexistem, não se excluem, donde afastado o pedido de desclassificação. A condição de usuário não elide a responsabilização do agente pelo tráfico de drogas, pois é comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, o qual vende entorpecente para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira).

Assim como o fato de se tratar de um rapaz jovem, negro, morador de uma comunidade humilde tenha sido o motivador de uma prisão, porque os policiais não conheciam o

réu e vice-versa, e nada tinham um contra o outro, não sendo crível que tivessem imputado injustamente o crime ao réu, que não sua conduta de portar e trazer consigo, drogas, como presenciado pelos policiais, sem prova contrária, pois nem mesmo um vizinho que fosse e que tenha presenciado a prisão, foi arrolado a confirmar que várias pessoas correram, e não apenas duas, e que não seria o réu o traficante, e que o policial teria retornado com uma pochete e indevidamente atribuído ao réu a posse, junto com ameaças e agressões físicas. Dito isso, afasto pedido da defesa de desclassificação para crime mais brando dado que o réu alegou não ter feito a compra de uma maconha para si, e a quantidade e diversidade de drogas apreendidas, além da quantia em dinheiro afastam suposição de que estaria na biqueira, o que ele não nega, apenas para compra de uma substância.

À luz do art. 28, § 2º, da Lei 11.343/06, a natureza da droga (cocaina), o local da prisão (um ponto de venda de drogas conhecido), o alto valor apreendido (fl.223) são fatores que, reunidos, permitem a conclusão indubitável de que o elemento subjetivo do agente dirigia-se especificamente à mercancia e não ao mero consumo pessoal, de modo que a procedência do pedido é inarredável.

Passa-se, pois, à dosimetria da pena.

Observado o art. 59 do Código Penal, os motivos, circunstâncias e consequências do delito a não demandar aumento inicial na pena, mas sim a excessiva quantidade de narcóticos apreendidos (222 no total), às vistas do disposto no art. 42 da Lei de Drogas, fixo em primeira fase, a pena base acima do mínimo legal, ou seja, em 06 anos de reclusão e 600 dias-multa.

Em segunda fase, não há circunstâncias agravantes nem atenuantes a serem consideradas, restando a pena inalterada nessa etapa.

Em terceira etapa, não concorrem causas de aumento de pena. Quanto ao privilégio previsto no §4º, do art. 33, da Lei 11.343/06, trata-se de réu primário (fls.190/193), mas por outro lado, considerando a natureza das drogas altamente viciantes e prejudiciais à saúde (cocaina e crack), além da alta quantia em dinheiro apreendida (mil e duzentos reais) a indicar vendas efetivamente feitas à usuários, disseminando o vício e o fomentando, tudo demonstrando maior dedicação e envolvimento com a traficância ilícita, opto pelo percentual de redução de 1/3, totalizando 04 anos de reclusão e 400 dias-multa, cada qual fixado em 1/30 do valor do salário mínimo atual tendo em conta ausência de elementos nos autos indicativos da capacidade financeira do Condenado.

Incabível a benesse do art. 44 do CP, não se mostrando suficiente nem eficaz à reprovação da conduta do agente, menos ainda socialmente recomendável sob pena de potencializar a sensação de insegurança e intranquilidade social, a merecer maior reprovabilidade a conduta, dado que viola mais intensamente o bem jurídico tutelado, somado ao elevado número de ocorrências de tal natureza conferindo constante desassossego à sociedade, a exigir firme repressão do Estado como forma de desestimular o crime, geralmente cometido graças ao nível de organização próprio daqueles que fazem do tráfico seu meio de vida. Não bastasse isso, o artigo 44, caput, da Lei de Drogas veda, expressamente, a substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direitos para o condenado pelos crimes previstos nos artigos 33, caput e parágrafo 1º, e 34 a 37. Já o artigo 33, parágrafo 4º, da Lei de Drogas, que prevê uma causa de diminuição de pena, também estabelece, no caso de sua aplicação, que a pena privativa de liberdade não poderá ser substituída por restritiva de direitos. Ainda, a 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de não ser possível a aludida substituição para o condenado por tráfico de drogas e condutas correlatas (artigos 33, caput e parágrafo 1º, e 34 a 37), bem como quando da aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei de Drogas (HC 144.915/MG, Rel. Laurita Vaz, v.u., j. 01.06.2010. No mesmo sentido – STJ – HC 136.618/MG, 5ª t., Rel. Min. Laurita Vaz,

v.u., j. 01.06.2010). ... Ora, não nos parece razoável proceder a substituição para autor de crime de suma gravidade. A personalidade, a conduta social e culpabilidade do traficante de drogas e de quem de qualquer forma o auxilia, bem como as consequências do crime, que são nefastas para o viciado e usuário e para a sociedade, não recomendam a substituição, que pode ser indeferida nos termos do artigo 44, III, do Código Penal. Ressalte-se, por fim, que a droga é o câncer que assola a todo o mundo já que, direta ou indiretamente, é responsável por boa parte dos crimes violentos que o afligem. Por causa dela as pessoas matam ou são mortas. É muito difícil um crime violento não ter a droga como estopim. Ou o agente está sob seu efeito, ou é vítima de um traficante ou de um drogado, ou é um traficante que mata um rival etc. Enfim, a droga, de uma maneira ou de outra, está ligada aos crimes mais graves.

Fixo o regime prisional semiaberto, considerando a quantidade da pena e primariedade do réu de um lado, mas também a preponderância da natureza e da quantidade da droga cocaína/crack, não ficando o juiz obrigado a fixar regime inicial relacionado unicamente com o quantum da pena, podendo optar por um mais gravoso ao observar a regra do artigo 33, parágrafo 2º, do Código Penal, em conjunto com o artigo 42 da Lei 11.343/2006, a teor do disposto nos artigos 33, do Código Penal. Nesses termos temos: Conforme entendimento jurisprudencial consolidado nesta Corte, não constitui bis in idem a utilização do fundamento com base na quantidade expressiva de droga apreendida para elevar a pena-base e, também, para estabelecer o regime prisional." (AgInt no REsp 1.539.980/PR, j. 11/04/2019).

Reconheço a custódia cautelar do Condenado desde a data do fato, sem reconhecer-lhe direito à detração penal ou à progressão de regime, tendo em vista os critérios legais objetivos. Assim, deixo de me manifestar sobre a detração penal, parecendo mais adequado que o juízo da execução se manifeste por primeiro, observando-se também os princípios constitucionais do duplo grau de jurisdição, da individualização da pena e do juiz natural. Não bastasse isso, progressão de regime é matéria a ser apreciada pelo juiz da execução, competente para tanto, nos moldes do art. 112 da LEP, caso contrário, o preso provisório obteria um benefício sem se verificar, primeiramente, se preenche os requisitos da referida Lei especial, que prevalece sobre a geral.

Neste sentido, posicionamento do E. Superior Tribunal de Justiça: A previsão inserida no § 2.º do art. 387 do Código de Processo Penal, não se refere à verificação dos requisitos para a progressão de regime, instituto que se restringe à execução penal, mas da possibilidade de o Juízo de 1.º Grau, no momento oportuno da prolação da sentença, estabelecer regime inicial mais brando, em razão da detração. Ainda que realizado o desconto do quantum da pena, do período em que o réu se manteve em custódia preventiva, não há óbice de que o magistrado fixe regime inicial mais gravoso, fundamentando-se nas circunstâncias do caso concreto, que recomendam maior rigor no cumprimento da pena (STJ, 5.ª Turma, HC n.º 361092/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 05/11/2015, grifei). Raciocinar em sentido contrário seria admitir uma espécie de "progressão de regime" pelo juízo criminal (que não tem competência para tanto), sem a análise dos requisitos objetivos e subjetivos estabelecidos pela Lei de Execuções Penais.

Custodiado no curso do processo, o Condenado não poderá exercer o direito de recorrer em liberdade, com mais razão ante a pena aplicada após exauriente cognição e diante do necessário resguardo da ordem pública e da aplicação da lei penal, constatada ausência de vínculos firmes no distrito da culpa, estando desempregado, além de ser incongruente soltá-lo, inclusive para a segurança pública e para a conveniência da aplicação da lei penal. (...) Não há lógica em permitir que o réu, preso (...) durante toda a instrução criminal, aguarde em liberdade o trânsito em julgado da causa, se mantidos os motivos da segregação cautelar (...) (STF HC nº

89.824/MS Rel. Ministro Ayres Britto Dje. 28.08.2008; STJ RHC nº 111.421/RJ, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, j. 03.10.2019, DJe 10.10.2019; RHC nº 118.468/MG, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, j. 17.10.2019, DJe 25.10.2019; RHC nº 34.998/RJ Rel. Ministro Jorge Mussi Dje 20.03.2013).

Por fim, não há valor mínimo de reparação do dano a ser arbitrado.

DISPOSITIVO.

Posto isso, JULGO PROCEDENTE A PRESENTE AÇÃO contra WILSON JOAQUIM FERREIRA JUNIOR, qualificado às fls. 04/06, pela prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, e o faço para condená-lo à pena de 04 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais ao pagamento de 400 dias-multa, cada qual fixado em 1/30 do valor do salário mínimo a época dos fatos corrigido monetariamente à data do efetivo pagamento.

Condeno-o, ainda, ao pagamento das custas e despesas processuais no valor de 100 Ufesp's, nos termos da lei nº 11.608/03, ante a constituição de Advogado(a).

O condenado não poderá apelar em liberdade. Recomendo-o no cárcere compatível com o regime ora fixado.

Declaro a perda em favor da União do valor apreendido nos autos (fls. 223), que deverá ser transferido ao FUNAD (após o trânsito em julgado), e fica desde já autorizada a incineração dos entorpecentes , a destruição de objetos .

Com o trânsito em julgado desta sentença, opere-se a detração penal, certifique-se e extraia-se a guia de recolhimento definitiva em relação à pena corporal, encaminhando-se à V.E.C. competente, certifique-se o cálculo da pena de multa, intime-se o réu a paga-la em 10 dias, e em 60 dias as custas, sob pena de extração de certidões da Sentença para a Procuradoria Geral do Estado (dívida ativa.

Oficie-se ao Senad, ao IIRGD e TRE.

Publicada em audiência, saem os presentes cientes e intimados. Cumpra-se.

Diadema, 24 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA